

1501695-25.2021.8.26.0568

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Elaní Cristina Mendes Marum

Comarca: São João da Boa Vista

Foro: Foro de São João da Boa Vista

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... reiteradamente, ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.

Consta ainda que, no dia 14 de setembro de 2021, por volta de 20h, na Rua Armando Landiva, 10, nesta cidade e Comarca, os acusados armazenavam e traziam consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte porções de cocaína pesando 14,3 g e uma porção de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São João da Boa Vista

Foro de São João da Boa Vista

Vara Criminal

Avenida Doutor Octávio da Silva Bastos, 2150, São João da Boa Vista-SP - cep 13874-149

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501695-25.2021.8.26.0568 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501695-25.2021.8.26.0568

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2250775/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 20249284 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 3427/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2250775 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEANDRO HENRIQUE ALVES DE CAMPOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaní Cristina Mendes Marum

Vistos.

KAMILY HELENA TEIXEIRA MARTINS e LEANDRO HENRIQUE ALVES DE CAMPOS foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei 11.343/06, em

razão de em data anterior, até o dia 14 de setembro de 2021, na Rua Armando Landiva, 10, nesta cidade e Comarca, terem se associado para o fim de praticar reiteradamente, ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.

Consta ainda que, no dia 14 de setembro de 2021, por volta de 20h, na Rua Armando Landiva, 10, nesta cidade e Comarca, os acusados armazenavam e traziam consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte porções de cocaína pesando 14,3 g e uma porção de "Cannabis sativa L.", com peso de 1,76 g, substâncias essas que causam dependência física e psíquica.

Os acusados foram presos em flagrante, sendo a custódia do réu convertida em prisão preventiva e concedida liberdade provisória à acusada.

Os acusados foram notificados e depois de apresentarem defesa preliminar, foi a denúncia recebida em 10 de dezembro de 2021, sendo determinada a citação dos réus.

No curso da instrução foram inquiridas as testemunhas arroladas, seguindo-se os interrogatórios dos acusados.

Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a absolvição dos acusados em relação ao delito de associação, e a condenação dos acusados pelo delito de tráfico.

A Defensoria do acusado, a seu turno, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no artigo 28 da Lei de Tóxicos, e subsidiariamente, requereu a redução e fixação da pena e regime prisional com menor rigor. A Defesa da ré pugnou pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com fixação da pena e regime de forma menos gravosa.

É o relatório.

Decido.

Na ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, ambos os acusados preferiram manter-se silentes (fls. 8/9).

Em juízo, a ré negou os fatos a ela atribuídos, e alegou que foi com o acusado Leandro à biqueira para comprar drogas para o uso dele. Informou que o menino que vendia entorpecentes "soltou" droga para um casal, e quando ele ia fornecer droga para a interroganda e para Leandro, a polícia chegou e correu atrás dos dois meninos.

Salientou que Leandro comprou seis pinos de cocaína, pelo valor de R\$ 10,00 cada um, e disse que o corréu lhe repassou essa droga. Afirmou que não sabe o nome do traficante que lhes vendeu a cocaína, e argumentou que não havia nenhum carrinho, porque seu filho estava em seu colo e no colo do acusado.

Mencionou que já estavam com a porção de maconha, que também era destinada ao uso de ambos, e que foi comprada no mesmo dia, em outro horário. Destacou que as únicas pessoas que estavam perto eram o casal que esperava droga e o menino que lhes vendeu a cocaína. Salientou que entregaram R\$ 110,00 para o traficante, e que receberam R\$ 50,00 de troco.

Asseverou que o acusado não foi até nenhum carrinho de bebê. Negou ter confessado aos policiais a venda de drogas e sustentou que não prestou depoimento na delegacia. Comentou que acredita que tenha sido acusada porque quando era adolescente, os policiais disseram que iriam prendê-la quando a interroganda

completasse a maioria.

Reiterou que a cocaína seria usada por Leandro, enquanto que a maconha seria usada por ele e pela interroganda. Asseverou que não estavam vendendo drogas. Sustentou que foi junto com o réu para comprar drogas porque teve medo do seu companheiro andar sozinho pela rua, porque “teve vários fatos quando ele era menor”.

Não soube explicar por que entregaram R\$ 110,00 para o traficante, e disse não se recordar se estava com uma cédula de R\$ 100,00. disse, ainda, que depois de comprar a maconha, o acusado ficou com ela durante o dia e a levou para o local de trabalho (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Por sua vez, o acusado Leandro também negou a traficância que lhe foi atribuída, e narrou, em seu interrogatório judicial, que depois de chegar do serviço, foi comprar seis pinos de cocaína para usar. Mencionou que quando desceu, os policiais tentaram abordar os meninos que vendiam drogas, tendo a policial feminina encontrado seis pinos de cocaína que estavam com a acusada.

Informou que pagou R\$ 60,00 pela droga, e que como tinha uma cédula de R\$ 100,00 e outra de R\$ 10,00, entregou todo o dinheiro e recebeu R\$ 50,00 de troco. Destacou que a cocaína seria destinada somente ao seu uso, e sustentou que chamou a ré para ir junto, porque tinha horário de recolhimento domiciliar. Sustentou que não havia ninguém com carrinho de bebê.

Argumentou que somente manteve contato com o menino que lhe vendeu a droga, e destacou que a ré não manteve contato com esse menino. Informou que também havia um casal que estava na frente dos mesmos. Negou que tivesse confessado a prática de tráfico aos policiais, e alegou que estava com a maconha, tendo ganhado tal droga quando comprou a cocaína.

Disse que o vendedor da cocaína lhe deu o baseado de maconha, que seria era somente para o interrogando usar. Aduziu que a acusada não iria usar droga. Negou que estivesse vendendo drogas. Admitiu que responde a outro processo por tráfico, e alegou que não comprou droga, e que não costuma levar entorpecente para seu local de trabalho, pois não usa droga no serviço (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Todavia, as negativas dos acusados, além de pouco convincentes, restaram contrariadas pela prova produzida no processo.

O policial Marcos Alexandre Cardoso narrou que recebeu uma denúncia no dia dos fatos, no sentido de que os acusados efetuavam tráfico no cruzamento de duas ruas, e que usavam o filho do casal, de poucos meses de idade, para traficar, deixando parte da droga no carrinho do bebê.

Salientou que ficou observando os acusados, e que viu quando a ré fez contato com três pessoas, e que recebeu e entregou algo para elas, em situação de tráfico. Mencionou que retornou à viatura, e que pediu apoio da policial Kelem para fazer a abordagem. Narrou que os réus foram abordados, e que em poder da acusada foram encontrados seis pinos de cocaína e R\$ 50,00.

Comentou que na rua foi encontrado o carrinho de bebê, onde foram localizados mais quatorze pinos de cocaína e R\$ 20,75. Sustentou que os acusados confessaram que praticavam o tráfico, porque passavam por necessidades. Disse não se lembrar se os pinos que estavam no carrinho eram iguais àqueles apreendidos com a ré e comentou que os acusados também admitiram que o dinheiro apreendido era produto do tráfico.

Aduziu que os réus não pareciam drogados e nem portavam objetos para consumo de drogas. Salientou que havia inúmeras denúncias de tráfico contra o casal, que era conhecido nos meios policiais desde a adolescência. Mencionou que durante todo o

período de observação, a criança estava no colo do réu, e ficou presente no local de venda da droga.

Disse, ainda, que como os compradores de droga rumavam em sentido oposto àquele que o depoente estava, não foi possível abordá-los. Aduziu que não se recorda do modo que o dinheiro se apresentava. Afirmou que antes não abordou os réus nesse cruzamento, mas já os viu anteriormente no local (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

No mesmo diapasão, o depoimento do policial Gian Carlos Vicente de Souza, que contou que recebeu denúncia de que os acusados estariam traficando no cruzamento das Ruas Marcos Antônio Valim e Armando Landiva e que usavam um bebê para ludibriar a polícia. Mencionou que foi ao local, e que observou a ré fazendo contato com três pessoas, tendo a ré recebido algo e entregado alguma coisa para essas pessoas.

Destacou que o réu subiu a rua com a criança no colo, foi até um carrinho de bebê, pegou algo nesse carrinho e entregou para Kamily. Narrou que os réus foram abordados, e que em poder da acusada foram encontrados seis pinos de cocaína e R\$ 50,00, enquanto que em poder do réu foi localizada uma porção de maconha. Salientou que no carrinho foram encontrados mais quatorze pinos de cocaína e R\$ 20,75.

Aduziu que os réus foram indagados, e que ambos confessaram a prática do tráfico, dizendo ainda, que o dinheiro encontrado era proveniente das vendas de droga, e que estavam praticando o tráfico em razão das condições financeiras. Informou que não se recorda se os pinos de cocaína apreendidos com a ré eram iguais àqueles encontrados no carrinho e disse que os acusados não aparentavam estar drogados e nem portavam objetos para uso de drogas.

Informou que já havia denúncias anteriores de tráfico contra os acusados, que eram recebidas em separado e disse que não conseguiu ver exatamente quais eram os objetos trocados entre os réus e os terceiros (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Diante de tais relatos, e considerando que no dia dos fatos os acusados foram vistos juntos na esquina, tendo a ré mantido contato com três pessoas e trocado objetos com elas, enquanto que o acusado foi visto se dirigindo a um carrinho de bebê e nele pegado algo, sendo encontrados nesse carrinho quatorze pinos de cocaína e dinheiro, ao passo em que em poder da ré foram encontrados mais seis pinos de cocaína e dinheiro, e na posse do acusado foi localizada uma porção de maconha, é de se entender que restou comprovada a traficância atribuída a ambos os acusados.

Essa conclusão mais se justifica porque além dos contatos e das trocas de objetos feitas entre a acusada e os terceiros serem características do tráfico, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, e notadamente a quantidade de pinos de cocaína, é incompatível com a que poderia ser destinada ao consumo dos réus, indicando a posse do dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada, que se tratava do produto da traficância, tendo os acusados admitido informalmente aos policiais a prática do tráfico e dito que o dinheiro foi auferido com a venda das drogas.

Ademais, as versões dos acusados não foram convincentes, pois ele próprios caíram em contradição ao tentar explicar a suposta compra de entorpecentes para uso pessoal, tendo a ré alegado que a maconha foi comprada anteriormente, em outro local, e que seria destinada ao consumo de ambos os réus, enquanto o acusado sustentou que ganhou a maconha do vendedor de cocaína, na própria ocasião dos fatos, sendo os dois tipos de entorpecentes destinados ao seu consumo exclusivo.

E ainda que os réus tivessem alegado que o carrinho de bebê que estava próximo da esquina não lhes pertencia, tal versão restou contrariada pelo depoimento do

policial Gian, que narrou ter visto o réu se dirigir a esse carrinho e nele pegar algo, sendo encontrados no carrinho quatorze pinos de cocaína e dinheiro, tudo indicando que essa droga também seria comercializada pelos acusados, os quais, aliás, estavam com um bebê no colo, exatamente para ludibriar a polícia.

E mesmo que os réus também fossem usuários de entorpecentes, tal fato não elide a traficância a eles atribuída, porquanto não são raros os casos de usuários que também se dedicam ao tráfico, como forma de manter o próprio vício e de conseguir dinheiro sem esforço, pelo que não prospera a solução desclassificatória almejada pela Defensoria.

Observo, ainda, que apesar das testemunhas serem policiais militares, tal fato não pode servir para elidir a condenação do acusado, uma vez que:

“Seria verdadeiro contra-senso que, aos agentes de segurança, deferisse o ordenamento jurídico determinada tarefa, para, depois, negar, aprioristicamente, valor a seus testemunhos, quando dela viessem prestar contas (TACRIM/SP, AC -Rel. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 92/352)”.

Prozada a autoria delitiva do tráfico, a materialidade delitiva restou confirmada pelos laudos de fls. 113/114 e 116/117.

Todavia, os elementos constantes dos autos são insuficientes para a caracterização, com certeza, do crime de associação.

E isso se justifica porque pelo que se depreende do relato do policial Gian Carlos, as denúncias anteriores contra os réus eram recebidas em separado, não havendo notícias de que tenha sido realizada alguma outra diligência para confirmação de que essa situação de associação dos réus para o ilícito comércio se repetia com frequência e com estabilidade, pelo que, diante da dúvida, merecem os acusados ser absolvidos quanto à imputação de terem cometido o delito descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, já que a mera coautoria não pode ser confundida com a associação.

Nesse sentido, confirmam-se as seguintes lições de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi (Lei de Drogas Anotada – Lei 11.343/2006, 1a ed., São Paulo, Saraiva, p. 120):

“Poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível, prevista naqueles artigos, para a incidência do delito agora comentado, em virtude da cláusula 'reiteradamente ou não'. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria.”

Passo à fixação da pena.

a) Com relação à acusada:

Extrai-se dos autos que a acusada é primária (fls. 48). Todavia, embora as drogas não se destinassem exatamente ao filho de tenra idade que os acusados possuem, e que estava no colo dos réus na ocasião dos fatos, para não despertar suspeitas da polícia acerca da traficância que realizavam na esquina, tal fato revela a maior gravidade concreta da conduta, já que um infante de tenra idade foi exposto a atividade criminosa, motivo pelo qual fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legal, ou seja, cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três

dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei.

Na segunda fase de dosimetria da reprimenda, reconheço a menoridade da ré como circunstância atenuante, e reduzo a pena em um sexto, mas como nesta etapa, não cabe a redução da sanção aquém do patamar previsto em lei, fica a reprimenda fixada em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Diante da primariedade da acusada, e tendo em vista que não há elementos de que ela se dedicasse a atividades delitivas (além daquela que embasa a presente condenação) ou integrasse organização criminosa, com base no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, face à quantidade de entorpecentes apreendidos, ou seja, 4,5 g líquidos de cocaína e 1,94 g líquidos de maconha. Desse modo, a sanção irá perfazer um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa.

No que pertine ao regime prisional, além do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal já terem manifestado posicionamento no sentido de que o tráfico com a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não é delito hediondo (STF. Plenário. HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016 e STJ. Pet nº 11.796/DF), a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o artigo 122 da LEP, sendo previsto no § 6º de tal dispositivo, que: "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins desse artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Diante de tal alteração legislativa, e revendo meu anterior entendimento, como o crime em questão não é mais considerado como hediondo, face à quantidade da sanção, merece ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Salienta-se, ainda, que em que pese a redução da pena privativa de liberdade, não se mostra cabível a sua conversão em pena restritiva de direitos, pois apesar da Resolução nº 5 do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, tal benefício não é possível diante das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista os efeitos nocivos do crime de tráfico de entorpecentes, que são fonte de outros tipos de criminalidade, e revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública e o bem estar social, mormente com a venda de cocaína de maior e potencial lesivo.

Assim sendo, não restaram atendidos os pressupostos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, ou seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente", de modo que ainda que se cuide de delito praticado sem violência e nem grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é adequada, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal.

Nesse sentido, já se decidiu que:

"Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou." (STJ - HC nº 203.403/SP, C. 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21/06/2011).

b) Com relação ao acusado:

Extrai-se dos autos que o acusado já foi preso em flagrante por outro crime de

tráfico, sendo-lhe concedida liberdade provisória (fls. 41), mas como ainda não foi condenado definitivamente, é de ser considerado como tecnicamente primário. Todavia, embora as drogas não se destinassem exatamente ao filho de tenra idade que os acusados possuem, e que estava no colo dos réus na ocasião dos fatos, para não despertar suspeitas da polícia acerca da traficância que realizavam na esquina, tal fato revela a maior gravidade concreta da conduta, já que um infante de tenra idade foi exposto a atividade criminosa, motivo pelo qual fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legal, ou seja, cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei.

Na segunda fase de dosimetria da reprimenda, reconheço a menoridade do réu como circunstância atenuante, e reduzo a pena em um sexto, mas como nesta etapa, não cabe a redução da sanção aquém do patamar previsto em lei, fica a reprimenda fixada em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na terceira fase de fixação da pena, ainda que o acusado seja primário, como este já foi preso em flagrante duas vezes, pela prática de tráfico e de furto (fls. 41), tal fato indica a reiteração delitiva, e denota que não se cuida de traficante iniciante, pelo que é de se entender que o acusado já se dedicava anteriormente às atividades delitivas, não preenchendo o réu os requisitos subjetivos para que lhe seja concedida a redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Ante a quantidade de pena fixada, a reiteração delitiva do acusado, a gravidade do delito em tela, que é equiparado a hediondo, e tendo em vista que o tráfico constitui inegável fonte de outros tipos de criminalidade, e que põe em risco a ordem pública, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo o acusado iniciar o cumprimento de sua reprimenda em regime fechado, observando-se que a custódia do réu, além de garantir a aplicação da lei penal, também se destina a resguardar a ordem pública, prevenindo que em liberdade, volte a se envolver no ilícito comércio.

Observa-se, ainda, que no tocante à detração do período em que o réu já permaneceu preso, o mero cumprimento do lapso temporal não é suficiente para a concessão de regime prisional mais brando, já que isso equivaleria à verdadeira progressão de regime feita sem a análise do necessário requisito subjetivo, sendo mais adequado que em sede de execução, o acusado comprove o preenchimento de seu mérito e lá postule eventual progressão de regime a que considere ter direito.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de:

a) CONDENAR KAMILY HELENA TEIXEIRA MARTINS como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Fixo-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei. Outrossim, ABSOLVO a acusada da imputação de ter cometido o delito descrito no artigo 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b) CONDENAR LEANDRO HENRIQUE ALVES DE CAMPOS como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Fixo-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei. Outrossim, ABSOLVO o acusado da imputação de ter cometido o delito descrito no artigo 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Estando o réu encarcerado, e tendo em vista a quantidade da pena e o regime prisional impostos, a sua reiteração delitiva e os demais motivos acima expostos, e que ora reitero, não lhe concedo o direito de apelar desta sentença em liberdade. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra, oficiando-se.

Com relação à acusada, considerando o regime prisional fixado, concedo-lhe o direito de apelar sem necessidade de recolhimento à prisão.

Oportunamente, oficie-se ao IIRGD e ao cartório eleitoral, devendo, ainda, ser expedidas guias de recolhimento, e com relação à ré, ser expedido mandado de prisão e termo de audiência de advertência.

Tendo em conta que os elementos constantes dos autos denotam que o dinheiro apreendido era produto do ilícito comércio, mesmo porque não foi comprovada sua origem lícita, decreto o perdimento do numerário em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Expeça-se, ainda, certidão de honorários pela atuação da Defensora dativa.

Custas, na forma da lei, ressaltando-se sua exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São João da Boa Vista, 21 de junho de 2022.

Elaní Cristina Mendes Marum
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA